

1500123-48.2021.8.26.0240

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA

Comarca: Iepê

Foro: Foro de Iepê

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194757/2021 - DEL.POL.IEPÊ, 19123966 - DEL.POL.IEPÊ, 252/21/206 - DEL.POL.IEPÊ, 2194757 - DEL.POL.IEPÊ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO PIAGENTINI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iepê

Foro de Iepê

Vara Única

Rua: Minas Gerais, 343, Iepe-SP - cep 19640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500123-48.2021.8.26.0240 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500123-48.2021.8.26.0240

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194757/2021 - DEL.POL.IEPÊ, 19123966 - DEL.POL.IEPÊ, 252/21/206 - DEL.POL.IEPÊ, 2194757 - DEL.POL.IEPÊ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO PIAGENTINI MACIEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA

Vistos.

EDUARDO PIAGENTINI MACIEL, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 330 do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 19 de julho de 2021, por volta das 12h00, na Rodovia Prefeito Jorge Bassil Dower, KM 106, nesta cidade e comarca de Iepê, EDUARDO PIAGENTINI MACIEL, qualificado à fl. 07, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, a saber, os Policiais Militares Elias Nunes

Cavalheiro e Jefferson Jose Coimbra.

Consta ainda que, nas exatas condições de tempo e espaço acima descritas, EDUARDO PIAGENTINI MACIEL, transportava e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 576 (quinhentos e setenta e seis) tijolos de maconha acondicionados em invólucros plásticos, pesando no total 496,600g (quatrocentos e noventa e seis quilos e seiscentos gramas), e um invólucro plástico contendo cocaína, pesando no total 0,73g (setenta e três centigramas) de massa líquida, drogas capazes de causar dependência física e psíquica, conforme Portaria da ANVISA nº 344/1998, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/28, fotografias de fls. 24/26, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 58/59 e laudos periciais definitivos de fls. 194/196 e 197/199.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 6/8), em 19 de julho de 2021. Por decisão de fls. 107/110, foi decretada a prisão preventiva.

A denúncia foi oferecida em 18 de agosto de 2021 (fls. 1/5).

O réu foi notificado (fl. 262) e apresentou defesa prévia (fls. 219/228), acompanhada de documentos (fls. 228/241).

A denúncia foi recebida às fls. 263/265.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 282/283 e 305/306), foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Às fls. 309/311, foi reavaliada e mantida a prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sobreveio laudo pericial do aparelho celular (fls. 345/350).

Em alegações finais (fls. 353/365), o Ministério Público requereu a condenação do réu. Quanto à dosimetria da pena no tráfico de drogas, requereu: a) Na primeira fase, aumento da pena base pela culpabilidade (anormal diante da complexa atuação de transporte dos entorpecentes, pelo contexto da prisão em flagrante do réu, com aparatos de fuga já preparados), pelas circunstâncias (veículo preparado para o transporte da imensa quantidade de droga), pelas consequências (utilização de caminhos alternativos em veículos preparados para o crime, dificultando a atuação das forças públicas e facilitando a dispersão de entorpecentes) e pela quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas); b) Na segunda fase, requereu a aplicação da agravante do art. 61, II, j, do CP (calamidade pública) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP); c) Na terceira fase, requereu a causa de aplicação da pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06 (transporte entre estados da federação) e afastamento da causa de diminuição do art. 33, parágrafo quarto da mesma lei.

Em alegações finais (fls. 380/436), a Defesa requereu a aplicação da pena no mínimo legal e regime semi-aberto ou aberto; ressaltou a confissão espontânea como atenuante; pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06, em sua redução máxima, com substituição pela pena restritiva de direitos. Reforça que o réu é primário e não integra organização criminosa. Por fim, pleiteou o direito de o réu recorrer em liberdade.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos fatos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6/8); pelo Boletim de Ocorrência de fls. 27/29; pelo auto de exibição e apreensão e pelas fotografias das drogas apreendidas às fls. 30/33, 34/40, 41/44, 45, 46, 47/48, 49/53; pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 63/64 e pelos laudos periciais definitivos de fls. 199/201, 202/204 e 345/350, além da prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou comprovada.

Elias Nunes Cavalheiro, policial militar em juízo relatou que se encontravam em fiscalização próximo ao município Iepê na SP-421, onde foi dado sinal para o condutor do veículo Focus mas este desobedeceu a ordem de parada e arremessou o veículo sobre a equipe; que saíram em perseguição e o condutor acionou um dispositivo de fumaça no veículo e jogou alguns miguelitos para obter êxito em sua

fuga; que alguns quilômetros à frente, o réu tentou adentrar em um canavial, onde perdeu o controle, chocou-se com um barranco, continuando a empreender fuga a pé em meio a canavial, mas foi acompanhado e detido; que, ao verificar o veículo, notou-se uma grande quantidade de drogas no interior do veículo; questionado, o réu relatou estar recebendo a quantia de 2.000,00 (dois mil) reais para conduzir o veículo da cidade Porecatu/PR até o município de Paraguaçu Paulista/SP, alegando ter sido contratado por pessoa desconhecida, não sabendo também para quem iria entregar a droga. Que então foi conduzido até a delegacia para demais providências. Foi encontrado no veículo por volta 500 (quinhentos) quilos de drogas que estavam à mostra, sendo o veículo totalmente tomado pelo entorpecente. Quanto ao dispositivo, afirmou ser semelhante ao apresentado em filmes da década de 80 (oitenta), sendo acionado por um botão no painel do automóvel, sendo inclusive testado para verificação, mas nada ocorreu, pois teria acabado o líquido que promove a fumaça. Ao ser abordado, o acusado chorava muito e não discorria sobre os questionamentos, alegando apenas que uma pessoa desconhecida o havia contratado e que teria pego o veículo na cidade Porecatu/PR e iria deixá-lo em Paraguaçu Paulista/SP, não dizendo nada mais.

Jefferson José Coimbra, policial militar, apresentou em juízo a mesma versão da testemunha anterior, relatando que se encontravam no local dos fatos em fiscalização, quando foi dado o sinal de parada obrigatório ao veículo que era conduzido pelo réu, sendo um Ford Focus, de cor prata, e ele desobedeceu ao sinal realizando uma arrancada brusca, projetando o veículo em direção à equipe, tentando evadir-se, tendo este que sair rapidamente para não ser lesionado; que a equipe embarcou rapidamente na viatura e realizou o acompanhamento; que durante o trajeto, foi utilizado pelo réu um dispositivo que dispersava fumaça, com objetivo de dificultar a visualização de seu automóvel; que o réu arremessou também alguns artefatos de nome miguelito, para furar o pneu da viatura, visando impedir que a equipe se aproximasse do acusado, sendo ambas as trapaças superadas. Que pouco à frente, o acusado tentou evadir-se fazendo uso de uma estrada de terra que fica às margens da rodovia, momento no qual perdeu o controle e chocou-se contra um barranco, adentrando no canavial correndo, empreendendo fuga, sendo logo detido. Que no veículo, foram localizados quase 500 (quinhentos) quilos de entorpecentes. Estes que eram de fácil visualização, não havia os forros das laterais do veículo, sendo o automóvel provavelmente utilizado para a prática de outros delitos, como transporte de cigarro, pois não tinha os bancos traseiros, tampouco os forros laterais.

Questionado pelo Ministério Público, a testemunha respondeu que o veículo utilizado pela equipe era uma Bm Trailblazer, com velocidade máxima de 184 (cento e oitenta e quatro) km/h, com 210 (duzentos e vinte) cavalos a diesel, com cilindradas de 2.8 (dois/ oito) turbo diesel; disse ainda que foi percorrido pelo veículo Ford Focus por volta de 5 quilômetros de fuga, demorando por volta de 03 (três) a 04 (quatro) minutos até que o réu se chocasse contra o barranco. Disse ainda que o veículo do réu estava a um quilômetro de distância e foi possível visualizar uma grande cortina de fumaça, porque havia um aclive no ponto quem que o acusado tentou empreender fuga pela estrada à margem da rodovia, adentrando a área lindeira; disse também que acredita ter sido possível detê-lo pois o acusado perdeu o controle do veículo e tentou evadir-se a pé.

Interrogado, o réu Eduardo Piagentini Maciel disse que estava desempregado e sua esposa estava passando por uma gravidez de risco, motivo pelo qual acabou pegando dinheiro emprestado; que estava com as parcelas de sua casa atrasadas, passando dificuldades; que quando chegou a data de pagar o valor emprestado não tinha o dinheiro, então recebeu uma ligação onde lhe foi dito que haveria um veículo em um lugar específico e que ele deveria pegar o este e conduzi-lo até Paraguaçu Paulista/SP, que assim seria compensado o valor devido; relatou que estava sendo obrigado a ir, devido a algumas ameaças e pela também pela dificuldade que estava passando, pois não iria deixar o seu filho passar necessidades; disse que sentiu desespero e que teve que fazer isso por sua família, pois estava desempregado.

Disse desconhecer a identidade de quem o contratou, pois pegou o dinheiro emprestado com um agiota na cidade (de Porecatu/PR) e ele lhe disse que teria que fazer um serviço para um cara que lhe telefonaria e, ao questionar quem era, foi dito que não era necessário que ele soubesse a identidade dessa pessoa, dizendo que ele deveria apenas fazer da forma como fosse orientado, assim poderia compensar a dívida com esse agiota.

Questionado pelo Ministério Público, respondeu que a quantia devida se tratava de mais de 5.000,00 (cinco) mil reais, contudo, o credor iria descontar somente o valor de 2.000,00 (dois) mil reais para que o acusado realizasse o transporte. Informou que antes de ser preso não tinha emprego, motivo que o induziu a tomar tal decisão, pois não tinha como pagar a dívida. Relatou já ter respondido anteriormente por ter transportado cigarros. Disse que sua casa vale por volta de 100.000,00 (cem) mil reais, valor que paga na forma de parcelas mensais, não sabendo dizer quanto do valor de sua casa já foi pago até o presente momento. Disse que também não possui nenhum outro bem, apenas a residência, que foi financiada em 2017. Reiterou que foi obrigado, devido à situação em que estava, dizendo não saber o que seu credor poderia fazer com sua pessoa e sua família. Questionado quanto à gravidez de risco mencionada, e qual seria o tratamento que sua esposa teria feito para tal enfermidade, não soube discorrer; quanto ao nome do agiota, disse que iria se complicar caso revelasse a sua identidade, relatando que o conheceu como "salsicha" e o encontrou através de meninos que estavam no posto de combustível, e nesse mesmo local pegou quantia com a pessoa conhecida como "salsicha"; que após recebeu a cobrança e não tinha dinheiro para o pagamento da dívida; questionado pelo Ministério Público se não teria como ter pego com familiares ou banco, relatou que o nascimento de seu filho ficou mais de 10.000,00 (dez) mil reais e que seus parentes já o haviam ajudado nesta etapa; disse que pegou dinheiro com agiota devido ao desespero.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Conforme a denúncia, o réu foi surpreendido quando transportava e trazia consigo drogas, quase 500 quilos de maconha e uma porção de cocaína. A apreensão se deu em uma fiscalização de trânsito, em que policiais militares, na altura do KM 110 da Rodovia Prefeito Jorge Bassil Dower, avistaram um veículo modelo Focus e deram sinal de parada, ao que o motorista, desobedecendo a ordem emanada pelos milicianos e empreendendo fuga do local, seguiu seu trajeto, inclusive jogando o veículo contra os agentes, que por sua vez tiveram de correr para não serem atropelados. Em seguida, os policiais embarcaram na viatura e saíram em perseguição ao denunciado, que na tentativa de alcançar êxito em sua fuga soltava fumaça e apetrechos para furar pneus na pista, mas acabou colidindo o veículo em um barranco na altura do KM 106. O réu saiu do carro e, em perseguição, os policiais o alcançaram e constataram o transporte da droga, que vinha do Paraná com destino a Paraguaçu Paulista. Pois bem. Tais fatos narrados na denúncia foram confirmados pelo depoimento dos policiais em juízo, que detalharam a abordagem, a ordem de parada desobedecida, a perseguição, a captura do réu e a apreensão da droga. Os depoimentos prestados pelos policiais, cuja credibilidade é a mesma à de qualquer testemunha em juízo, são coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas acostadas aos autos, como os autos de exibição e apreensão das drogas e fotografias de fls. 49/53, que demonstram o veículo danificado. Anoto que, embora tenham sido juntadas na fase do inquérito, são elementos de natureza irrepetível, e por isso submetido, excepcionalmente, ao contraditório diferido.

Por fim, o réu confessou os fatos. Disse que foi contactado por pessoa desconhecida para fazer o transporte da droga do Paraná até a cidade de Paraguaçu Paulista, pelo valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), que seria abatido de uma dívida de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), existente com um agiota.

Passo à análise da tipificação das condutas imputadas ao réu.

Art. 330 do Código Penal

Tipifica o art. 330 do Código Penal a conduta de "Desobedecer a ordem legal de funcionário público". Trata-se de crime comum e formal. Além disso, para a configuração do delito em tela requer-se i) a existência de uma ordem emitida por funcionário público; ii) a individualização desta ordem a um destinatário certo;

iii) obrigação do destinatário de atendê-la; e iv) ausência de sanção especial para seu descumprimento. Quanto ao tipo subjetivo, o destinatário da ordem deve dela tomar ciência. (RHC 85.496/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

No caso em tela, os policiais emitiram a ordem de parada, vista e compreendida pelo réu, que, não obstante, efetuou manobra brusca e empreendeu fuga, foi perseguido e finalmente capturado.

Oportuno consignar que a jurisprudência recente de ambas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça estão alinhadas no entendimento de que configura o crime de desobediência a conduta do agente que não obedece a ordem de parada emanada de policial militar no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e repressão de crimes. Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DOS POLICIAIS NA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. FUGA DO AGENTE APÓS ORDEM DE PARADA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais, no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195, do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal.

2. Na hipótese dos autos, contudo, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1805782/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 334-A, § 1º, I, E 330, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO, EM SEGUNDO GRAU, DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA POR PARTE DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. CONDUCTA TÍPICA. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior já consolidou o entendimento de que "a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal".

2. Recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal.

3. A decisão agravada alterou a conclusão do Colegiado a quo pela reavaliação da moldura fática já delineada nos autos, o que foi demonstrado pela mera transcrição de trechos da sentença condenatória e do acórdão recorrido. Não incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1697205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 28/05/2019, DJe 04/06/2019)

Com base nas premissas jurídicas acima expostas e na prova oral produzido em juízo, reputo demonstrada a prática do crime de desobediência.

Art. 33 da Lei 11.343/06

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é

daqueles denominados 'tipo misto alternativo', que apresenta multiplicidade de verbos nucleares, sendo despendida a comprovação da comercialização, bastando a prática de quaisquer dos verbos cernes não sejam dotados do fim específico de uso pessoal. No caso em liça, o agir atribuído ao réu é “transportar” e “trazer consigo”, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Por sua vez, a finalidade da traficância é verificada pelas circunstâncias objetivas dos fatos, pois não é possível aferir, no íntimo do agente, a sua finalidade. Logo, a finalidade de traficância, elementar do tipo penal em questão, nos casos em que não houve a efetiva comercialização – como nas modalidades trazer consigo e transportar – é atestada pela exteriorização da conduta do agente, notadamente na forma em que foi flagrado e demais circunstâncias da apreensão da droga.

No caso em tela, a expressiva quantidade de droga apreendida - 576 (quinhentos e setenta e seis) tijolos de maconha acondicionados em invólucros plásticos, pesando no total 496,600g (quatrocentos e noventa e seis quilos e seiscentos gramas), e um invólucro plástico contendo cocaína, pesando no total 0,73g (setenta e três centigramas) de massa líquida) – revela, de forma inequívoca, a finalidade do tráfico. Ainda, o próprio réu confessou que foi “contratado” para transportar a droga de um estado para o outro para terceiros.

Ademais, as substâncias apreendidas foram submetidas à perícia, constatando-se a presença de “tetrahidrocanabinol”, substância psicoativa presente na “maconha”, assim como de cocaína, todas causadora de dependência e integrantes da Portaria 344/1998 do Ministério da Saúde (laudo pericial de fls. 194/196 e 197/199).

Por fim, o réu não dispunha de autorização para trazer consigo ou transportar as aludidas drogas.

Anoto que não prospera a tese defensiva de “desespero”, “dívidas”, “desemprego” ou “ameaças” – estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Primeiro, porque sequer restou comprovada nos autos (dificuldades financeiras, financiamento da casa própria, gravidez de risco e/ou nascimento do filho); segundo porque não há subsunção aos institutos jurídicos em questão. A propósito:

“Estado de necessidade e dificuldades econômicas: não se confundem. No estado de necessidade, o agente é compelido a praticar fato típico, para afastar situação de perigo atual ou iminente, involuntário e inevitável, capaz de afetar bem jurídico próprio ou de terceiro cujo sacrifício é inexigível. Na dificuldade econômica supõe-se que o indivíduo deva conformar-se com a privação, porque não se cuida do suprimento de necessidade vital ou primária. Ou, ainda que se trate disso que lhe seja possível satisfazer a carência por meio de atividade lícita”. (Cleber Masson, Código Penal Comentado, 9 ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, pag. 216).

No mesmo sentido o REsp 499.442/PE, 5ª Turma, j. 24/06/2003.

Além disso, conforme pontuado pelo Ministério Público em alegações finais (fl. 359), “no ano de 2020 o réu foi preso em flagrante pelo crime de contrabando (fl. 368) e apresentou as mesmas justificativas: desemprego e dificuldade financeira”. O fato de utilizar-se de estratégias previamente preparados (miguelitos e fumaça) e o veículo estar sem banco traseiro igualmente são indícios de que não se trata de um transporte ocasional, um ato desespero, como quis parecer o réu. Logo, considerando a comprovação da autoria e da materialidade, da tipicidade formal e material da conduta, bem como a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do réu é a medida que se impõe.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, d, do CP e afasto a agravante do art. 61, II, j, do CP, pois não há nexo de causalidade entre a conduta do réu e o estado de calamidade pública provocada pelo covid-19.

Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, considerando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça), conforme narrado na denúncia e confirmado pela instrução processual e inclusive confessado pelo réu (transporte da droga do estado do Paraná à cidade de Paraguaçu Paulista/SP), adequo a tipificação da conduta para aplicar a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Por fim, com relação à causa de diminuição de pena do art. 33, parágrafo quarto, entendo que não estão presentes os requisitos para sua aplicação, quais sejam, cumulativamente, agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, 2ª Turma, HC 152001 AgR, em 29/10/2019 e HC 154694 AgR/SP, em 4/2/2020), para fins de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, milita em favor do réu a presunção de preenchimento dos requisitos do parágrafo quarto do art. 33. Para afastar a minorante, pode ser utilizada, desde que apenas em uma das fases da dosimetria, como regra, a quantidade e variedade da droga (STF, plenário, ARE 666634, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral, Tema 712 - As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena -.; STF, 2ª Turma, RHC 122684/MG; STJ, 5ª Turma, HC 329.744/MS e STJ 6ª Turma, AgInt no HC 545.926/SP, julgado em 20/05/2020). Anoto ainda que há entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a utilização concomitante da quantidade de drogas na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, desde que como critério de reforço na comprovação de o réu integrar organização criminosa (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1259578/SP).

Em se tratando de réu primário, é possível utilizar, com análise criteriosa e no cotejo com as demais circunstâncias do caso concreto, a quantidade de drogas como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena.

Para a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 130981/MS, julgado em 18/10/2016, “não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 quilos de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo quarto, da Lei de Drogas”. Já na 2ª Turma, há precedente (RHC 138715/MS, julgado em 23/05/2017) no sentido de que a “quantidade de droga encontrada não constitui, isoladamente, fundamento idôneo pra negar o redutor”.

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE DE TESE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Para afastar a condenação do paciente em relação ao tráfico de drogas e concluir pela desclassificação da conduta a ele imputada para o crime previsto no art. 33, § 3º, do Código Penal, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 3. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. 4. Embora a Corte estadual tenha justificado a não incidência do redutor com base na quantidade de drogas apreendidas, a quantidade de substâncias encontradas em poder do paciente (24 frascos de lança-

perfume) não pode ser considerada excessivamente elevada a ponto de, por si só, levar a crer que ele se dedica a atividades criminosas ou possui acentuado envolvimento com o narcotráfico. Vale dizer, não se mostra razoável admitir que alguém que, isoladamente, é preso com 24 frascos de lança-perfume ostente a condição de traficante habitual, de modo a não ser merecedor do benefício em questão. 5. Não havendo sido apontados elementos concretos dos autos que, efetivamente, justificassem o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser concedido habeas corpus, de ofício, para reconhecer a incidência da minorante em questão e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que, à luz das especificidades do caso em análise, escolha a fração de diminuição de pena – de 1/6 a 2/3 – que entender adequada à espécie.(...). (HABEAS CORPUS Nº 351.976 – SP, rel.p/acórdão Min. Rogério Schietti, j. em 03/05/2016). Como se vê, interpretando-se os precedentes jurisprudenciais, e à luz do caso concreto, a quantidade exorbitante de droga apreendida – MEIA TONELADA DE MACONHA -, em veículo adaptado para o transporte de grande quantidade (retirado o estofado traseiro) e o réu preparado com aparato de fuga (fumaça e miguélicos), transportando drogas entre dois estados, configuram as circunstâncias exigidas pela jurisprudência para afastar a minorante. Feitas tais considerações, passo a dosimetria da pena.

Art. 330 do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria da pena, presentes circunstâncias judiciais negativas, consistentes na ameaça à integridade física dos policiais, pois, ao desobedecer ao comando de parada, o réu “jogou o veículo” contra os funcionários públicos responsáveis pela ordem legal, o que extrapola a tipicidade inerente ao delito. Sem outras circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 16 dias de detenção e 11 dias multa, pena que torno definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes bem como causas de diminuição e aumento de pena a modificar a pena.

Fixo o dia multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo.

Considerando a pena de detenção, o quantum de pena aplicado e a primariedade do réu, determino o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Tóxicos, a pena base deve ser aumentada em razão das circunstâncias da apreensão da droga, que envolveram perseguição a veículo com aparato de fuga, e preparado para o tráfico, o que extrapola a mera tipicidade do delito. Deixo de valorar negativamente a quantidade de droga na presente fase, sob pena de bis in idem (filiando-me ao entendimento da 6ª Turma do STJ, Agint no HC 545.926/SP, j. 26/05/2020 e ao Tema 712 do STF, sem a distinção feita pela 5ª Turma do STJ no AgRG no HC 549.034/SP, j. em 09/06/2020). Assim, fixo a pena base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes, motivo pelo qual a pena intermediária retorna ao patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, conforme exposto na fundamentação, presente a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas (1/6 a 2/3). Considerando a efetiva transposição da fronteira entre os estados, com grande quantidade de drogas (meia tonelada), aplico a fração intermediária de aumento de 1/3, tornando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Fixo o dia multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, pois embora o réu seja primário, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e a quantidade de drogas apreendida é elevada (STF, 2ª Turma, HC 133308/SP, j. em 29/03/2016).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para

CONDENAR o réu EDUARDO PIAGENTINI MACIEL, como incurso no art. 330 do Código Penal e no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, na forma do art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli), em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de 16 dias de detenção, em regime aberto, bem como à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, respectivamente, e ao pagamento de 677 dias multa, no dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Incabíveis os benefícios do art. 44 e art. 77 do Código Penal, dada a quantidade de pena aplicada.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juízo da Execução.

Em atenção ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, observe-se que o réu respondeu ao processo preso, nada tendo sobrevivendo no seu curso a alterar o juízo sobre a necessidade da imposição de sua prisão preventiva. Inclusive, com a prolação da sentença resta comprovada a autoria ao passo que nenhum fato superveniente alterou os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (fls. 107/110), posteriormente confirmada, inclusive em sede de Habeas Corpus (fls. 189/190). Assim, atendendo ainda ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva, pois as circunstâncias do caso concreto – grande quantidade de droga, transportada entre estados e com tentativa de fuga no momento da abordagem, com utilização de fumaça e miguéritos – recomendam sua manutenção.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva ; e) autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06; e f) decreto a perda dos valores e bens apreendidos em favor da do Funad, com fulcro no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06 (veículo).

P.R.I.

Iepe, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA